

1509873-76.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... flagrado "trazendo consigo" substância entorpecente, com o intuito de tráfico. Conquanto a tipicidade dessa conduta prescindida da demonstração da prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente a terceiro, sua subsunção à descrição legal tornar-se-á ainda mais evidente na hipótese de haver flagrância também dessa circunstância. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1509873-76.2022.8.26.0228 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 20 de junho de 2022, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de Direito o(a) Dr(a). FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1509873-76.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

MESSIAS APARECIDO TEIXEIRA DE LEMOS

Vistos.

MESSIAS APARECIDO TEIXEIRA DE LEMOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, em 26 de abril de 2022, por volta de 13h20, na rua Doutor Elias Chaves, 54, Comunidade do Moinho - Santa Cecília, nesta Capital, trazia consigo e guardava, para fornecimento a terceiros, 50 porções de maconha, contendo tetrahydrocannabinol, com massa líquida de 21 gramas, 110 porções de cocaína em forma de crack, com massa líquida de 31,5 gramas, e 37 porções de cocaína, com massa líquida de 8,9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida e a defesa preliminar foi apresentada. Durante a instrução, foram juntados documentos, bem como foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (audiovisual).

Memoriais (fls. 161/165, 204/209).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de R\$ 1.512,00, 1 celular, marca LG, 24 porções de maconha, com massa líquida de 8,7 gramas, 26 porções de maconha, com massa líquida de 12,3 gramas, 110 porções de cocaína em forma de crack, com massa líquida de 31,5 gramas e 37 porções de cocaína, com massa líquida de 8,9 gramas (fls. 3/4); pelo auto de constatação das

substâncias tetrahidrocannabinol e cocaína (fls. 24/27); e pelo laudo de exame químico-toxicológico, em que se atestou tratar de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no país (fls. 122/125).

Quanto à autoria é inconteste, diante da prisão em flagrante do agente, na posse do entorpecente apreendido em circunstâncias de mercancia, conforme testemunhos policiais.

Vejamos a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial militar João Gabriel Santos Tozarini falou que estavam em três na equipe na comunidade e viram um casal saindo de uma residência. Tentaram abordar e o réu fugiu para a residência do lado, subindo as escadas. A menina ficou na frente da escada. Seu parceiro subiu e informou que visualizou o réu jogando duas sacolas brancas pela janela, janela essa que dá acesso a linha do trem. Ele abordou o réu e com ele havia dinheiro. Em entrevista, o réu falou que na residência anterior havia mais drogas. Desceu, o outro parceiro verificou que na residência de onde saíram havia crack, maconha, cocaína, dinheiro e o celular do réu. A casa de onde saíram era abandonada; a segunda casa era de um proprietário que não conhecia o réu e autorizou a entrada dos policiais. Esperaram apoio e Guilherme e o outro policial pegaram as sacolas arremessadas, onde havia maconha. Havia mais de cem porções. Seu parceiro que fez a entrevista; segundo ele foi confirmado o tráfico. A mulher nada falou ao depoente, apenas que era namorado dela. Havia um morador no andar de baixo da segunda casa. Uma escada do lado de fora dá acesso ao segundo andar. Abordaram, pois o réu mudou a direção quando os viu e tinha um volume na cintura; não sabiam se era arma ou prática de crime. Não se lembra das roupas do réu. Avistou o réu e ele e a mulher andavam na direção da viatura duas rodas. Eles estavam a cerca de 10 metros. Há uma esquina ali. Quando abordaram começou a chegar pessoas. Ali há residências.

O policial militar Guilherme Simões Nunes asseverou que estava em patrulhamento na comunidade Moinho e é de conhecimento que há tráfico. Em uma das vielas viram um casal saindo de uma casa e parando em frente a outra, sendo que eles se beijaram. Desembarcou e o réu saiu correndo para uma construção, uma escada. Foi atrás e a mulher entrou na sua frente, mas se desvencilhou e subiu a escada. O réu jogou um saco para a linha do trem. As casas dão fundo para a linha do trem. O réu dispensou dinheiro em uma caixa no chão. Ele deu um monte de explicações. Solicitou apoio. Quando o apoio chegou desceram na linha do trem e na sacola havia maconha. Questionou o réu e ele admitiu o tráfico, sendo que na casa de onde ele saiu, abandonada, havia mais drogas e dinheiro. É uma construção, tipo um sobrado, com uma escada, sendo que havia uma casa de baixo, fechada com porta de madeira. São casas separadas. É uma construção, não havia nada. O dono da casa de baixo também é dono daquela construção. O réu saiu de uma ou duas casas ao lado, abandonada, de livre acesso, cheio de sujeiras. Como tudo é aberto, correu atrás do réu. Questionou o dono depois, que autorizou sim e inclusive agradeceu. Ele não conhecia o casal. Havia saquinhos de maconha na sacola; e cerca de um mil reais. Pediram apoio e saíram logo. A menina disse ser namorada do réu e depois que tinham se abraçado, pois ele se assustou. Depois, ela falou que não era; levou-a para averiguação. Ela tentou impedir a passagem do depoente, colocando o corpo na frente.

Ainda, o relato da testemunha civil, presencial, foi no mesmo sentido: Julia Thaissa Lima dos Santos: estavam de frente a sua casa namorando e os rocans vieram de uma rua e os enquadraram. Messias correu e entrou ao lado da casa de sua amiga. Não sabe por que ele correu. Foi para a casa de sua amiga e um rocam a abordou também. Não falou nada na delegacia. Já foi presa por tráfico de drogas. O máximo que falou foi com seu advogado. Não sabe se o réu vende drogas. Foi direto pra cela na delegacia e sua mãe chegou em minutos.

Destarte, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática dos fatos descritos na denúncia pelo réu.

E não se diga que o depoimento de policiais não merece credibilidade. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, civis ou militares, até mesmo porque seria um contrassenso

o Estado, que outrora os credencia para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chama à prestação de contas perante o Poder Judiciário, não mais lhes empreste credibilidade. Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência:

A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. (STF – HC 70.237 – Rel. Carlos Velloso – RTJ 157/94).

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF – HC 73.518- 5 – Rel. Celso de Mello – DJU 18.10.96 – p. 39.846).

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (STJ – HC 608.558 RJ 2020/0217527 – Rel. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 01.12.2020 – DJe 07.12.2020). Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais, no caso, merecem crédito e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente.

A negativa do denunciado em juízo não convence, diante do farto conjunto de provas em seu desfavor, principalmente diante da confissão extrajudicial. Ainda, as alegações não vieram comprovadas, na forma do que exige o artigo 156 do CPP, restando isoladas.

Segue o interrogatório.

O réu Messias Aparecido Teixeira de Lemos confessou os fatos na fase policial, as fls. 14. Em juízo, ele afirmou ter 22 anos, morar sozinho, ser chapeiro, já ter sido processado por furto, ter estudado até a sétima ou oitava série. Nega os fatos. Não chegou a falar com ninguém na delegacia. O depoimento já estava feito, não sabe o nome. Ficou com a menina na cela e depois foi ao fórum. Correu para a casa de cima, por medo por ter passagem. A casa não é do depoente.

Nota-se que a confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, desde que roborada por outros elementos de prova colhidos sobre o crivo do contraditório, serve de indício de autoria, possibilitando a condenação, desde que não refutada por outras provas ou contra-indícios, cujo ônus de produção incumbe à defesa. Confira-se, nesse sentido: O fato da confissão ter sido feita na fase de inquérito policial é irrelevante, de vez que, tal prova vale não em função do local em que venha a ser lançada, mas do grau de credibilidade que naturalmente lhe seja inerente. (TACRIM/SP – AC 741.041/4).

PROVA CRIMINAL - Confissão extrajudicial - Validade - Ocorrência - Embora retratada em juízo, vale a confissão desde que esteja em consonância com outros elementos de convicção - Recurso não provido. (Apelação Criminal 158.176-3 – Rel. Cunha Camargo – 28.04.94).

PROVA CRIMINAL - Confissão extrajudicial - Retratação em Juízo - Irrelevância - Validade não pelo local em que é prestada, mas pela força de convencimento - Impossibilidade de desprezo quando em harmonia com a prova da instrução - Condenação decretada - Recurso provido. (Apelação Criminal 152.166-3 – Rel. Renato Talli – 27.06.1994).

No mesmo sentido: RJDTACRIM 1/226, 6/133-134, 10/125, 11/54, 11/234, 15/68, 16/76-

77, 19/175, 20/71, 21/102-266, 22/276, 23/214, 25/318-477, 27/162 e 29/194. A confissão extrajudicial, elaborada perante a autoridade policial e sem as garantias do contraditório, fica subordinada à confirmação dos fatos em juízo. Nesse sentido, explica GUILHERME DE SOUZA NUCCI que “a confissão extrajudicial, não contando com as garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício” (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 454). Como explica TOURINHO FILHO, “assim, se perante a Autoridade Policial, alguém confessa haver praticado determinada infração, essa confissão será extrajudicial, e, se negada em juízo, terá, tão-somente, o valor de indício”. Isso porque, ainda conforme TOURINHO, “o valor da retratação, entretanto, é relativo. O Juiz tem absoluta liberdade de pôr em confronto a retratação com os demais elementos de prova carreados para os autos, a fim de constatar se a retratação é ou não sincera”. (Processo Penal, 31º ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 302-304). Assim, ocorrendo retratação da confissão em juízo, a confissão extrajudicial passa a ser mera prova indiciária, sendo necessária sua comprovação por outros meios de prova para assentar a condenação. Este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO ACERTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos. 2. In casu, não há se falar que a condenação do agravante pautou-se unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma vez que tal prova não restou isolada nos autos, estando suficientemente comprovada a responsabilidade penal do agravante. 3. Agravo regimental improvido” (STJ AgRg no AREsp 195746/RN – Rel. Min. Campos Marques – j. 21/02/2013). (TJSP – AP 1500157-86.2018.8.26.0544 – Rel. Lauro Mens de Mello – j. 12.12.2019 – DJe 19.12.2019). Observa-se que a confissão policial foi confirmada por testemunhas ouvidas em juízo, fato que autoriza a expedição de um decreto condenatório. Neste caso não se trata de mero indício produzido na fase policial, onde não existe o contraditório, mas sim de indício produzido na fase policial e confirmado por testemunha em juízo, sob o crivo do contraditório, que relatou os fatos com riqueza de detalhes. O fato de haver ocorrido retratação não afasta o valor probante, posto que, como exposto acima, ela foi confirmada por outros elementos de prova produzidos nos autos. A segunda versão, por outro lado, foi inverossímil e divorciada do conjunto probatório. Portanto, verifica-se que a confissão extrajudicial foi roborada pelas demais provas orais e, de acordo com a mansa e pacífica jurisprudência, deve-se dar maior credibilidade à confissão realizada na policial que a retratação em juízo, ainda mais, quando a primeira esteja amoldada às demais provas dos autos e a segunda seja inverossímil e divorciada do conjunto probatório. (TACRIM/SP – AP 1.231.709/3 – Rel. Francisco Menin – j. 22.03.2001 – v.u.). Além do mais, a confissão pode ser retratada, mas sem prejuízo do livre convencimento do juiz, que deve fundá-lo no exame das provas em conjunto (Código de Processo Penal, art. 200). (TACRIM/SP – AP 1.140.319/6 – Rel. Penteado Navarro – j. 07.04.1999 – v.u.). Uma vez que a retratação não veio amparada por elementos que a confirmem, impõe-se seu descarte, mantendo-se a confissão policial. CONFISSÃO POLICIAL – Retratação – Validade – Requisitos: Para a retratação da confissão ser válida, é necessário que seja verossímil, encontrando algum amparo, ainda que elementos indiciários ou circunstâncias. (TACRIM/SP – Rel. Passos de Freitas – RJDTACRIM 16/77). Agente que, em fase inquisitorial, confessa livremente a prática do delito – Posterior retratação em Juízo – Inocência pretendida – Impossibilidade – Condenação Mantida. - Mostra-se insuficiente para embasar sentença absolutória simples retratação em Juízo, a confissão feita na fase inquisitorial, quando esta for roborada pelos demais elementos de prova constantes nos autos. (TACRIM/SP – Rel. Silva Rico – RJDTACRIM 3/162).

Nota-se que a negativa pura e simples do réu, bem como a imputação de conduta

irregular aos policiais, sem motivo plausível ou indício de que os agentes da Lei, testemunhas e vítimas tivessem motivos para prejudicá-lo, não merece crédito. Ao contrário, o que se vê dos autos são provas firmes, fortes e categóricas a indicar a necessidade de responsabilização do acusado. As imagens das câmeras acopladas ao uniforme policial ratificam o conjunto probatório que aponta para a condenação. É certo que não estão integralmente apresentadas, mas isso não desqualifica os relatos testemunhais, até porque nas partes gravadas, coincidem com os relatos. Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no artigo 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de comércio, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de atos de cogitação e preparatórios.

Neste sentido: TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. (TJSP - AP 1.104.091-3/5 - Rel. Pinheiro Franco - j. 20.09.2007).

Tráfico de entorpecentes. Agente flagrado trazendo consigo e guardando 31,4 gramas de maconha, 1,6 gramas de cocaína sob a forma de "crack" e 0,9 gramas de cocaína em pó. Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório. Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Tráfico de entorpecentes Agente que traz consigo substância estupefaciente e é flagrado na prática de oferta gratuita ou de venda Caracterização Basta à realização do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 o fato do agente ser flagrado "trazendo consigo" substância entorpecente, com o intuito de tráfico. Conquanto a tipicidade dessa conduta prescindida da demonstração da prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente a terceiro, sua subsunção à descrição legal tornar-se-á ainda mais evidente na hipótese de haver flagrância também dessa circunstância. Tráfico de entorpecentes Diligência na qual policiais solicitam entorpecentes aos suspeitos de tráfico Caracterização e consumação prévias do crime em razão de conduta anterior do agente consistente em "manter", "guardar" ou "ter em depósito" substância estupefaciente A ação da polícia que envolva diligência na qual policial solicita e provoca a venda de entorpecentes ao suspeito de tráfico não deve ser confundida com a situação de flagrante forjado ou provocado, uma vez que a prática do crime de tráfico já estava caracterizada pela conduta anterior do agente, que veio regida pelos núcleos verbais "manter", "guardar", "ter em depósito" etc. Eventual participação ativa de policial na dinâmica do ocorrido, consistente na solicitação de entorpecente, consiste, pois, em proceder legítimo, na medida em que não acarreta qualquer interferência externa na realização ou não do tipo penal concernente ao tráfico, que já havia se consumado, independentemente da atuação dos policiais(...). Basta à realização do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com efeito, o fato do agente ser flagrado "trazendo consigo" substância entorpecente, com intuito de tráfico. Conquanto a tipicidade dessa conduta prescindida da demonstração da prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente a terceiro, sua subsunção à descrição legal tornar-se-á ainda mais evidente na hipótese de haver flagrância também dessa circunstância. (TJSP - AP 0028921-57.2016.8.26.0050 - Rel. Grassi Neto - j. 13.04.2020 - DJe 13.04.2020).

E não há que se falar em nulidade da prova, em razão da entrada dos policiais na residência onde havia a droga. Primeiro, pois era uma construção de livre acesso,

onde ninguém residia. Ali não era residência. E os policiais confirmaram que o dono da residência debaixo, que foi acionado, ratificou desconhecer o réu, em sua construção, assim como a mulher que estava em sua companhia. E autorizou a entrada em sua casa. Fato este ratificado pelas imagens captadas pela polícia.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP e no artigo 42 da Lei de Drogas, fixa-se a pena base no mínimo legal para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, em relação à atenuante da confissão, usada na fundamentação da condenação, não se admite que a pena seja diminuída para aquém do mínimo. Nesse sentido, a Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Nesse mesmo sentido: Menoridade. Circunstância atenuante que, todavia, não pode implicar redução da pena fixada no mínimo legal (STF – HC – Rel. Sidney Sanches – RTJ 118/928). Ainda: (RT 737/551, 735/535, 735/568).

Na terceira fase, tendo em vista a primariedade, os bons antecedentes e a inexistência de provas sobre a dedicação do réu a atividades criminosas ou a integração em organização criminosa, reconhece-se a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzindo-se a pena em 2/3, totalizando-se 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, “c” e § 3º, do CP, fixa-se o regime aberto de cumprimento de pena. Não há que se olvidar que o tema 600 do Recurso Repetitivo do STJ dispõe: O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. E por ter respondido o processo preso, poderá apelar em liberdade, diante da pena.

Diante do exposto, CONDENO o réu MESSIAS APARECIDO TEIXEIRA DE LEMOS às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, como incurso no artigo 33, caput, e § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Presentes os requisitos do artigo 44, caput, do CP e verificando-se que as medidas são socialmente recomendáveis, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, nos termos do artigo 46 do mesmo diploma, em local a ser indicado pelo Juízo das Execuções Criminais, descontado eventual período de custódia cautelar, e prestação pecuniária à entidade social no valor de um salário mínimo, que pode ser dividido. Nomeia-se a FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Banco do Brasil, agência 1897-X, conta corrente 8946-X.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o dispositivo da Lei n. 11.343/06 que proíbe expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, no HC 97256. Neste prisma: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIMENTO. DECISÃO BASEADA, APENAS, NA VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 44 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DENEGAÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. PENA. REGIME. LEI 8.072/1990. DISPOSITIVO QUE IMPUNHA O REGIME FECHADO PARA CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.

INCONSTITUCIONALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. I – Não obstante a vedação prevista no art. 44 da Lei 11.343/2006, o Plenário desta Corte, ao apreciar o HC 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da proibição de concessão de liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico, por ser incompatível com os princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. II – Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, sem prejuízo de que o magistrado de primeiro grau, caso entenda necessário, fixe, de forma fundamentada, uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do

Código de Processo Penal. III - Concessão da ordem de ofício para determinar ao juízo de piso que: i) superada a obrigatoriedade de imposição do regime fechado aos condenados por tráfico de drogas, avalie se o paciente preenche os requisitos para a fixação do regime aberto, ou, caso entenda pela imposição de regime mais grave do que o previsto para o quantum de pena, que o faça de forma fundamentada, e ii) afastado o óbice à conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, analise se o paciente preenche os requisitos para a referida substituição. (HC 114029-SP - Rel. Ricardo Lewandowski - j. 18.02.2012 - DJe 22.02.2013).

Nota-se que o Superior Tribunal de Justiça admite tal substituição, inclusive o regime aberto de cumprimento de pena, conforme julgados: STJ - HC184497-SP - Rel. Jorge Mussi - j. 07.02.2013 - DJe 19.02.2013 e HC 216197-RS - Rel. Laurita Vaz - j. 07.02.2013 - DJe 18.02.2013. Também nesse sentido: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL FECHADO E SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva de habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quanto o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Como é cediço, em se tratando de tráfico de entorpecentes, desde o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n. 111.840/ES, inexistente a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59 do CP. 3. Quanto à possibilidade de substituição da pena, nos delitos de tráfico, o Supremo Tribunal Federal, em 1/9/2010, no julgamento do HC n. 97.256/RS, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §4º do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei de Drogas, na parte relativa à proibição da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por tráfico de entorpecentes. Dessa forma, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por restritiva de direitos. 4. No caso, tratando-se de réu primário, condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, bem como considerada a quantidade não expressiva de droga apreendida, o paciente faz jus ao regime aberto, a teor do disposto no art. 33, §§2º e 3º, do CP, assim como resulta cabível a conversão da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. 5. Habeas corpus não reconhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais. (STJ - HC 463246 SP 2018/0200421-1 - Rel. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 18.10.2018 - DJe 26.10.2018). P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, expeça(m) ou adite(m)-se a(s) guia(s) de execução, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente; façam-se as comunicações; atualize-se o histórico de partes; archive-se; expeça(m)-se mandado(s) de prisão, se for o caso; uma vez cumprido(s), expeça(m)-se guia(s) de recolhimento, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente; caso o(s) réu(s) não seja(m) encontrado(s), aguarde-se em escaninho próprio, cobrando-se a cada 120 dias; ou designe-se audiência para regime aberto; deverá(ão) o(s) réu(s) ser intimado(s) no último endereço onde foi(ram) encontrado(s); caso o(s) réu(s) não seja(m) encontrado(s), expeça(m)-se mandado(s) de prisão, fazendo constar que o(s) réu(s) deverá(ão) ser imediatamente apresentado(s) a este Juízo para participar da audiência de regime aberto e, após, será(ão) posto(s) imediatamente em liberdade; decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o(a) proprietário(a) do(s) bem(s) apreendido(s) manifeste interesse na restituição, expeça-se ofício ao setor de armas e objetos, autorizando o leilão ou destruição, nos termos do artigo 123 ou 124 do Código de Processo Penal; oficie-se requisitando a incineração do entorpecente apreendido e das amostras guardadas para contraprova, nos termos do Provimento CSM 2482/2018; o dinheiro deverá ser revertido em favor do

FUNAD; se for o caso, requirite-se da autoridade policial a remessa da guia de depósito do valor apreendido, com prazo de 30 dias; findo, reitere-se, sob pena de crime de desobediência, oficiando-se à Corregedoria da Polícia Civil; fica(m) desde já o(s) réu(s) intimado(s) a pagar os dias-multa, em 10 dias a contar do trânsito em julgado, com consectários legais (Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta 139.521-1, Titular Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo); na hipótese de quitação, abra-se vista ao Ministério Público e, após, venham conclusos para declaração da extinção da punibilidade da pena de multa; caso não seja efetuado o pagamento da multa, encaminhe-se para cobrança.

São Paulo, 20 de junho de 2022.

FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA
Juiz(a) de Direito